

1502989-26.2021.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico, mormente a notícia recebida pelos policiais de que o acusado realizava o tráfico, na modalidade 'delivery', a apreensão de droga, o modo de embalagem do entorpecente, a apreensão do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502989-26.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502989-26.2021.8.26.0047 - 2021/002935

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAQUIM BRAIDE FILHO

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. JOAQUIM BRAIDE FILHO, qualificado nos autos (fl. 22), foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33. caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, nesta Cidade e Comarca, supostamente, mantinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 26 (vinte e seis) porções de cocaína, com peso líquido total de 26,88 g (vinte e seis gramas e oitenta centigramas) [fls. 179/181].

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fl. 178).

O acusado foi notificado (fl. 193) e, após a apresentação da defesa preliminar (fls. 196/204), a denúncia foi recebida (fls. 210/211).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, três testemunhas arroladas pela defesa, e o réu interrogado (fls. 253/254).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fls. 253/254), e do d. Defensor, pela nulidade da prova obtida no aparelho celular, pelo não reconhecimento de maus antecedentes, e ainda, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (fls. 253/254).

É o relatório.

2. Da alegação de nulidade da prova obtida no aparelho celular.

O d. defensor pleiteia a nulidade da prova obtida, alegando que não fornecido ao acusado e à esposa do denunciado, no momento da abordagem, cópia da autorização relacionada ao aparelho celular, afirmando ainda que a esposa do acusado se sentiu ameaçada pelos policiais quando da abordagem, de modo a fornecer o acesso do aparelho.

O afastamento do sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos por ocasião do cumprimento do mandado de busca foi deferido expressamente por este Juízo, nos autos 1502966-80.2021.8.26.0047 (fls. 10/13 do referido processo), ressaltando-se que cópia da decisão proferida serviria como mandado, a qual o acusado confirmou, em audiência, ter assinado.

Ademais, ressalta-se no momento do flagrante, ainda que os policiais tenham realizado algum acesso ao aparelho, teria sido o mero acesso a dados constatados visualmente nos registros existentes no aparelho telefônico, isto é, sem codificação no aparelho telefônico celular, o que não se confunde com as comunicações telefônicas, estas, sim, protegidas pela norma constitucional. Desse modo, não se constata nulidade.

2.1. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18) e pelos laudos periciais (fls. 11/13, 152/154 e 159/171).

Na fase policial o acusado aduziu que as drogas localizadas em sua residência são realmente do declarante, mas afirma ser usuário e nega comercializar os entorpecentes. Como possui passagem por homicídio, afirma que não gosta de frequentar 'biqueiras', e que comprou 30 (trinta) porções de uma só vez. Sua esposa sabe que é usuário, mas reitera não comercializar drogas. É viciado em cocaína. Trabalha como técnico em manutenção de piscinas e trabalha como autônomo. Sobre o dinheiro localizado, equivalente a R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), afirma ser referente à venda da casa onde reside junto com sua esposa, venda essa que afirma possuir contrato e que, posteriormente, pode apresentar e provar a origem do montante. Não esboçou qualquer resistência à prisão e ao cumprimento da busca domiciliar em sua casa (fl. 22).

Em Juízo o réu aduziu que está ciente da acusação. Havia 26 (vinte e seis) porções de cocaína no armário da lavanderia. Não havia drogas na caixa do correio, nem mesmo no interior do seu veículo. Estava dormindo quando escutou o portão da casa abrir. Foi verificar o que era aquele barulho, e recebeu voz de prisão. Os policiais pediram permissão para que pudessem ingressar na sua residência, tendo o interrogado autorizado. Em seguida, um dos castrenses mostrou o mandado de busca e apreensão, alegando que, caso o réu não apontasse o local em que estavam inseridos os narcóticos, o policial iria prender a esposa do denunciado por tráfico de drogas. O interrogado informa que a esposa não possui ciência 'do que acontece'. Afirmou ao policial que havia droga no imóvel, e que as porções eram para consumo próprio. Indagado, também informou aos castrenses que havia a quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais) em uma gaveta, e que o valor era proveniente da venda de um imóvel. Não possui arma de fogo. Possui passagem pela polícia, em decorrência de um homicídio ocorrido há 20 (vinte) anos. Não conhece os policiais que procederam a abordagem. Trabalha com manutenção. Afirma que pegava a porção de cocaína pelo valor de R\$ 20,00 (vinte reais) e 'passava para pessoas com quem possui vínculo de amizade', por R\$ 50,00 (cinquenta reais). Havia cerca de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) em sua carteira, mas o restante, cerca de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), era proveniente da alienação de um imóvel. Iria utilizar os R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para comprar materiais de construção. A venda da residência foi realizada 3 (três) meses antes dos fatos. Possui contrato e recibo da venda do imóvel. Na data do ocorrido, o seu celular estava no quarto, com a esposa. Não assinou nenhum documento autorizando o acesso dos policiais ao seu celular. Assinou apenas o mandado de busca e apreensão (fls. 253/254).

O Policial Civil Marcelo Maciel obtemperou que na data do corrido, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do acusado, visando apreender drogas e uma arma de fogo. Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos entorpecentes em um armário da lavanderia do imóvel, bem como no interior do veículo do réu, e ainda próximo a uma caixa de correio, no quintal da casa. Também foi apreendido

dinheiro, no quarto do denunciado e na lavanderia da residência. Na ocasião, foram também apreendidas embalagens semelhantes às que geralmente são utilizadas para embalar narcóticos. O celular do acusado foi apreendido. Foram encontradas algumas conversas no aparelho celular do réu relacionadas a mercancia da droga. Quando indagado, o denunciado acabou confessando, informalmente, que vendia entorpecente pelo valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) cada unidade. Diante dos fatos, o réu foi conduzido até a Delegacia. Por haver autorização, o denunciado foi questionado e acabou desbloqueando o celular para que fosse averiguado. A DISE possuía informações de que o acusado estava comercializando drogas na modalidade 'delivery', na cidade. O depoente já havia identificado o réu e localizado o lugar onde ele residia. Paralelamente às investigações, a DIG recebeu informações de que o denunciado estaria na posse de uma arma de fogo. Tomou conhecimento de que a DIG iria realizar uma busca no imóvel do acusado, e solicitou à Autoridade Policial que permitisse a DISE acompanhar as diligências, pois já possuíam informações de que o réu estava envolvido na traficância. Foi isso que culminou nas buscas especializadas. Encontrou 2 (duas) porções de entorpecentes, sendo uma da cocaína 'amarela' e outra da cocaína 'branca'. O entorpecente estava solto entre o câmbio do automóvel e o painel. Na ocasião da abordagem, explicou ao denunciado que no mandado de busca e apreensão havia autorização judicial para o acesso ao aparelho celular. A autorização judicial foi apresentada ao acusado (fls. 253/254). O Policial Civil Marcelo de Souza asseverou que na data do ocorrido, foi cumprir um mandado de busca e apreensão, onde possuía a informação de que o acusado estaria na posse de uma arma de fogo. O réu também já estava sendo investigado por tráfico de drogas. Deslocou-se até a residência do denunciado. Na ocasião, o acusado recebeu os policiais de imediato. Indagado acerca da existência de algo de ilícito no imóvel, como arma de fogo e entorpecentes, o acusado afirmou que não havia arma de fogo, mas apenas algumas porções de cocaína, tendo indicado o local em que estavam inseridas. Os narcóticos estavam na parte externa da residência, na lavanderia, no interior de um armário. As drogas estavam inseridas em um 'saquinho'. Havia 23 (vinte e três) porções. Em continuação às buscas, foi localizado no interior do veículo mais 2 (duas) porções da mesma droga, e mais 1 (uma) porção no 'muro', inserida na caixa de correio. No interior do automóvel do réu, foi encontrada cerca de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie e, no interior do imóvel, no quarto, havia o equivalente a R\$ 3.000,00 (três mil reais). O aparelho celular do denunciado foi apreendido. No mandado de busca e apreensão havia a autorização para que o celular fosse vistoriado. Foi solicitado ao acusado permissão para que pudessem olhar o celular. O réu liberou o acesso e, em algumas mensagens do WhatsApp, havia conversas relacionadas ao comércio de drogas. Indagado sobre o valor encontrado no interior do veículo, o denunciado afirmou que era de sua propriedade. Em relação à quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais), o acusado informou que o montante era proveniente da venda de um imóvel e que poderia comprovar posteriormente. O mandado de busca e apreensão foi apresentado ao réu e para sua esposa. Não foi realizada campana. Havia informações do investigador chefe da DISE de que o denunciado estaria realizando o comércio de entorpecentes na modalidade 'delivery' (fls. 253/254).

A testemunha Maria de Lourdes disse que conhece o acusado pois ele comparecia de vez em quando no seu bar. Não frequentava a residência do réu. Não tem conhecimento sobre o envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas. Nunca 'presenciou nada' (fls. 253/254).

A testemunha Victoria falou que conhece o acusado, mas não presenciou os fatos. A depoente comprou uma residência do réu juntamente com seu namorado, que fica localizada na Rua Manoel Gomes, número 65, no Parque Colinas. Não se recorda da data da compra, pois foi feita pela 'Caixa'. Adquiriu a residência pelo valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), e deu cerca de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) de entrada do financiamento ao acusado e sua esposa (fls. 253/254).

A testemunha Soelaine aduziu que o acusado é seu esposo. Estava no local no momento dos fatos. Os policiais chegaram em sua residência por volta das 06h00, em uma segunda-feira. Estava dormindo juntamente com o réu. A janela do quarto estava aberta. Os castrenses chegaram e logo pediram para que a depoente ficasse no

quarto. Estava sem roupa, e os castrenses não a deixaram se vestir. Não viu o que os policiais conversaram com o réu. O aparelho celular estava no quarto. Os castrenses perguntaram se o celular possuía senha, e pediram para que a depoente a fornecesse. Conseguiu desbloquear o aparelho. Os policiais disseram que 'o assunto era com o denunciado, mas caso ela não colaborasse, o assunto iria ser com ela também'. Sentiu-se ameaçada pelos castrenses. Não foi apresentado nenhum mandado de autorização judicial. Os policiais já chegaram 'pegando tudo', inclusive, abriram até o 'cofre de sua filha', e pegaram as moedas de R\$ 0,10 (dez centavos) e de R\$ 0,50 (cinquenta centavos). Não foi apresentado nenhum mandado autorizando os policiais a terem acesso ao aparelho celular. A quantia apreendida equivalente a R\$ 3.000,00 (três mil reais), é proveniente da venda de um imóvel e iria utilizar o montante para comprar 'laje'. Não chegou a visualizar as drogas apreendidas. Os 'sacos', geralmente utilizados para fazer geladinhos, eram utilizados pela depoente para fazer gelo, pois produzia produtos derivados de 'kefir'. Tem um relacionamento com o denunciado desde 2 de novembro de 2019. Não possui conhecimento sobre o acusado possuir algum vício. Desconfiava que o réu consumia drogas, mas nunca teve certeza. Não chegou a ver o local onde foi apreendido o entorpecente (fls. 253/254). Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação dos acusados é medida de rigor.

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico, mormente a notícia recebida pelos policiais de que o acusado realizava o tráfico, na modalidade 'delivery', a apreensão de droga, o modo de embalagem do entorpecente, a apreensão do dinheiro, e a extração de dados do aparelho celular (fls. 159/171), o que bem demonstra a finalidade da mercancia, ressaltando-se, ainda, a confissão extrajudicial, quando da abordagem policial, bem como a confissão judicial, pois o acusado afirmou em Juízo que pegava a porção de cocaína pelo valor de R\$ 20,00 (vinte reais) e 'passava para pessoas com quem possui vínculo de amizade', por R\$ 50,00 (cinquenta reais).

É sabido que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo, para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absoluta ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 -

São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente ou isente os acusados de pena, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Vale lembrar que, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, in casu, permaneceram no cômodo terreno do alegar por alegar.

2.1. O acusado é reincidente (processo nº 0011491-15.2003.8.26.0417 - execução nº 0004086-43.2017.8.26.0996) - cf. F.A. e Certidões de fls. 44/46 e 47/49).

Logo, fixa-se a pena base no mínimo legal.

Em seguida, a reincidência é compensada pela confissão, considerada na fundamentação, nos termos da Súmula 545 do E. STJ.

Por fim, a reincidência desautoriza a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Rejeitada a preliminar, julgo procedente o pedido acusatório para condenar JOAQUIM BRAIDE FILHO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, o que melhor se coaduna à espécie, em razão da reincidência e da gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo.

O montante da pena corporal e a reincidência desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que tal benefício é incompatível com a repercussão social e a periculosidade inerente ao delito, devendo-se, ainda, assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, recomendando-o na prisão em que se encontra, mormente em razão da reincidência.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro e do aparelho celular apreendidos, em favor da União (fls. 17/18), mormente se for considerado que não restou demonstrada a origem lícita dos referidos bens, nem mesmo pelos documentos de fls. 63/76 e 84.

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Assis, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA